

1503461-32.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... em ponto indicado como de tráfico, é de ser condenado nos termos da imputação inicial, cabendo ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1503461-32.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040145/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 22966637 - 72º

D.P. VILA PENTEADO, 2040145 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL HENRIQUE TOLEDO

Vítima:

SOCIEDADE

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

12/05/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 12 de maio de 2022, às 15:19 horas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências criada dentro da Plataforma Microsoft Teams para audiências por videoconferência, com a concordância prévia e expressa das partes, por requisição do juízo da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LUCIANA PIOVESAN, comigo Escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Márcia Leite Macedo. Presente(s) o(s) réu(s) RAFAEL HENRIQUE TOLEDO- PRESO E REQUISITADO - CDP VILA INDEPENDÊNCIA, assistido pela Defensora Pública, Dra. Fernanda Corrêa da Costa Benjamim. Iniciados os

trabalhos, pediu a palavra a representante do Ministério Público e por e foi requerida a juntada de documento, referente a ação penal que tramita no Juízo da 14ª Vara Criminal Central, o que foi deferido pela MM. Juíza, com ciência à Dra. Defensora Pública. A seguir após prévia identificação, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) de acusação/defesa Testemunha/A: GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA PM e Testemunha/A: CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS PM, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizados no sistema ONE DRIVE e acessível mediante link. Em seguida, após entrevista reservada com seu defensor, foi o réu INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizados no sistema ONE DRIVE e acessível mediante link. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: RAFAEL HENRIQUE TOLEDO foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 09h00, na Avenida Michihisa Murata, altura do nº 222, bairro Freguesia do Ó, nesta capital e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de comércio, 18 (dezoito) invólucros plásticos e 32 (trinta e dois) pinos plásticos com cocaína; 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos com crack; 19 (dezenove) invólucros plásticos com maconha e 15 (quinze) frascos de vidro de lança perfume. sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão de fls. 06/07 e laudo de constatação de fls. 09/12 (fotografia de fls. 13). É dos autos que policiais militares faziam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram RAFAEL colocando uma bolsa preta atrás de uma máquina de lavar, que estava na calçada, sentando-se em seguida. Ao perceber a polícia, RAFAEL se levantou e foi para sentido contrário da via, quando abordado. Em revista pessoal, trazia consigo R\$26,00 em dinheiro. Contudo, atrás da referida máquina, foi localizada a bolsa preta que estava nas suas mãos, contendo todas as drogas acima referidas. De pronto, assumiu a prática da mercancia dos entorpecentes, que realizava desde a noite anterior, para receber R\$200,00. Preso em flagrante e interrogado perante autoridade policial, o denunciado confessou a prática criminosa (fls. 18). A forma de acondicionamento dos entorpecentes, ainda junto de quantia em dinheiro, bem como as circunstâncias da abordagem policial, somada à ampla confissão, evidenciam que as substâncias eram destinadas ao comércio ilícito. Ofertada denúncia, foi determinada a notificação do réu para ofertar defesa preliminar e, com a juntada desta, houve recebimento da denúncia, determinação de citação do acusado e designação de audiência única. Na instrução do feito foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Laudo de exame químico toxicológico foi juntado a 100/102. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico toxicológico de fls. 100/102, que comprova que as substâncias apreendidas eram maconha, cocaína e TRICLOROETILENO. Da mesma forma, diante do conjunto probatório coligido, restou comprovada a autoria delitiva por parte do réu. Senão, vejamos: O policial militar Cássio Henrique declarou que na data dos fatos estavam realizando patrulhamento pela via, quando entraram na rua mencionada na denúncia, e viram o acusado escondendo uma bolsa preta atrás de uma máquina de lavar que estava na rua. Ele estava distraído. Ao vê-los, ele tentou se afastar. Como o local é conhecido pela venda de drogas, suspeitaram, e resolveram abordá-lo. Com ele não acharam nada de ilícito. Foram buscar a bolsa que ele havia escondido atrás da máquina, e lá acharam maconha, cocaína e crack. O réu disse que estava trabalhando desde a noite anterior, e que receberia duzentos reais por turno. O acusado tinha dinheiro com ele, mas não lembra a quantia. Não se lembra da quantidade de drogas apreendidas, mas já estava embaladas para venda, e era uma quantidade considerável. Não havia outras pessoas na via naquele momento, não no local onde ele estava. Estavam bem próximos do réu quando viram ele escondendo a bolsa, não sabe precisar a distância, mas de onde estava não havia dúvidas da ação do acusado. Nunca havia abordado o réu anteriormente. O policial militar Gustavo declarou que na data dos fatos estavam

realizando patrulhamento pela via, local conhecido pelo tráfico de drogas, e viram o acusado de posse de uma bolsa preta, que ele colocou atrás de uma máquina de lavar que estava na via para descarte. No que ele viu a viatura, ele deixou a bolsa lá e tentou se afastar. Por isso, o abordaram, e não encontraram nada com ele. Porém, pega a bolsa que o viram escondendo, lá encontraram diversas porções de entorpecentes, já separadas para a venda. Ele admitiu que estava traficando drogas no local desde a noite anterior, sendo que recebia duzentos reais por turno. Não o conhecia antes dos fatos. Havia maconha, cocaína e crack, e lança perfume. A quantidade exata não se recorda. Foi encontrado dinheiro também, mas não lembra a quantia, era um valor pequeno dentro da bolsa. A máquina de lavar estava na via pública, para momento, foi na parte da manhã. Estavam bem próximos do réu quando viram ele escondendo a descarte, na frente de uma residência. Não se recorda se havia outras pessoas na via naquela bolsa, não sabe precisar a distância. Ele estava desatento, e não viram, e de onde estavam não havia dúvidas da ação do acusado. Estavam com a viatura. O réu confessou a prática delitiva. Traficava drogas, e ganhava duzentos reais por turno. Estava “trabalhando” desde a noite passada. Estava com a bolsa com as drogas que foi apreendida pelos policiais. Já conhecia os policiais que o prenderam, e nada tem contra eles, que inclusive lhe deram conselhos na delegacia. É casado mas não tem filhos. Já foi processado por tráfico, mas não sabe o desfecho daquele processo, porque o fórum estava fechado. Está totalmente arrependido. Desse modo, diante do quanto declarado pelos policiais, comprovada a ocorrência do crime aqui apurado, ainda mais que eles detiveram o acusado escondendo a bolsa com as drogas, e o próprio réu confessou a prática do crime. Saliente-se que não há qualquer impedimento ou suspeição, a priori, no depoimento de policiais, sendo certo que a alegação de má conduta dos agentes policiais deve vir amparada em algum elemento de prova. Nesse sentido já entenderam os Tribunais Pátrios: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MERA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE DE PROVAS. VIA ELEITA INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação. 2. Acolher a tese de inocência defendida pelo Impetrante-Paciente, desconstituindo condenação transitada em julgado para a acusação e para a defesa, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. 3. Habeas corpus não conhecido(HC 195.200/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 03/05/2012)”. Ante o exposto, requeiro a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL, com a consequente CONDENÇÃO do réu nos termos do artigo 33 da Lei de Drogas. Sobrevindo decisão condenatória, é de se observar que o réu, não obstante primário, já foi condenado em Primeira Instância pelo delito de tráfico de drogas, sendo que, em setembro de 2021 ele foi colocado em liberdade e, menos de seis meses depois, foi preso novamente traficando, a demonstrar seu envolvimento com a criminalidade mais organizada e reiteração delitiva. Ressalte-se que ainda que a r. sentença do processo anterior não tenha ainda transitado em julgado (pois não se deu ciência da decisão, às partes, assim que tal foi prolatada), é certo que, conforme as cópias que ora se junta, verifica-se que naquele outro feito o acusado também foi confesso, ou seja, não há dúvidas de que ele, assim como o foi dessa vez, estava vendendo drogas. Saliente-se, também, que o acusado alegou ganhar duzentos reais por turno de “trabalho”, de modo que, ainda que ele trafique apenas 20 dias por mês, auferir renda superior a três salários-mínimos, a demonstrar o porquê de preferir a traficância a emprego regular e lícito. Com certeza a concessão do privilégio do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas a dois processos seguidos, isso com a prisão do agente logo depois de sua condenação em Primeira Instância, não é o que pretendeu o legislador pátrio ao criar a figura do tráfico privilegiado, não sendo cabível a quem fez da venda de entorpecentes seu meio de vida. No mais, em face da gravidade do crime cometido, o único regime aplicável é o fechado, sem concessão de pena substitutiva. Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito:MM. Juíza, Rafael Henrique Toledo foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo a acusação, no dia 11 de fevereiro de 2022, por

volta das 09h00, na Avenida Michihisa Murata, altura do nº 222, bairro Freguesia do Ó, nesta capital e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de comércio, 18 (dezoito) invólucros plásticos e 32 (trinta e dois) pinos plásticos com cocaína; 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos com crack; 19 (dezenove) invólucros plásticos com maconha e 15 (quinze) frascos de vidro de lança perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O processo transcorreu regularmente, com notificação do acusado, oferecimento de defesa prévia e recebimento da denúncia. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final. O PM Cassio relatou que no dia dos fatos estava em patrulhamento com seu parceiro (Gustavo) e quando entraram nessa via viram o réu escondendo uma bolsa preta atrás de uma máquina de lavar. Quando ele notou a presença da equipe saiu andando em sentido contrário, o que motivou a abordagem. Disse que o local é conhecido pelo tráfico. No local em que ele havia escondido a bolsa constataram que em seu interior havia cocaína, crack e maconha. Ele foi questionado sobre a droga e disse que estava vendendo drogas desde a noite anterior e que no final do turno ganharia 200,00. Não conhecia o acusado de data anterior. Indagado se havia dinheiro com ele, respondeu que sim, mas não se lembra quanto. Questionado sobre a quantidade de droga, falou que não se lembra, mas não era quantidade normal para uso. Falou que não havia mais ninguém na rua quando avistaram o réu. Disse que estava próximo quando viu o réu escondendo a bolsa. A testemunha Gustavo, PM, prestou depoimento no mesmo sentido que seu colega de trabalho. Disse que havia drogas variadas, mas não sabe precisar a quantidade. Essa máquina de lavar estava na via pública, aparentava ser descarte. Não se lembra se havia mais alguém na rua além do réu. Era período da manhã. Quando viram o réu esconder a bolsa estavam próximos dele, estavam na viatura. Em seu interrogatório Rafael admitiu a acusação, afirmando que realmente estava na venda de drogas. Encerrada a instrução, a ação deve ser julgada improcedente. Os depoimentos dos policiais não podem servir de fundamento único para a condenação. Imprescindível seria a produção de prova mais robusta que comprovasse, sem deixar qualquer dúvida, que o acusado estivesse traficando. Embora o réu tenha admitido a acusação, sabe-se que a confissão não é prova absoluta, não bastando, por si só, para fundamentar uma condenação. Diante do exposto, requer seja o réu absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Em caso de entendimento diverso, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, por não se revestir a conduta de reprovabilidade maior do que a já trazida pelo crime. Na segunda fase, deve incidir a atenuante da confissão espontânea. Requer-se, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, na medida em que o réu é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Quanto ao processo mencionado pela acusação, nota-se que não há condenação definitiva. O entendimento dos tribunais superiores é no sentido de que tão-somente a existência de ações penais, sem trânsito em julgado, não pode justificar o afastamento da minorante. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Em caso de descumprimento, o regime deve ser o aberto, tendo em vista a primariedade e a pena a ser aplicada. Requer, por fim, seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em homenagem ao princípio da presunção da inocência e à garantia do duplo grau de jurisdição, ambos assegurados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica). A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença: Vistos. RAFAEL HENRIQUE TOLEDO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, trazia consigo, para fins de comércio, 18 (dezoito) invólucros plásticos e 32 (trinta e dois) pinos plásticos com cocaína; 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos com crack; 19 (dezenove) invólucros plásticos com maconha e 15 (quinze) frascos de vidro de lança perfume. Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido convertida sua prisão em preventiva, por ocasião da comunicação do flagrante ao juízo. Notificado, o réu apresentou defesa preliminar à fl. 82. A denúncia foi

recebida à fl. 83 e depois foi o réu citado. O laudo de exame químico toxicológico foi juntado às fls. 100/102 dos autos. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, a representante do Ministério Público se manifestou em debates orais, pugnando pela procedência da ação, por entender comprovados os fatos descritos na denúncia diante da prova produzida. Requereu, ainda, ante a notícia, comprovada nos autos, da condenação do réu pela prática de outro crime de tráfico, seja afastada a aplicação do privilégio, com fixação do regime fechado para início de cumprimento de sua pena. A Defesa, noutro giro, requereu a absolvição, a alegar frágil a prova acusatória. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas nos mínimos legais, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial aberto para fins de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é de ser julgada procedente, a despeito da combatividade da Defesa. A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pela documentação fotográfica de fls. 28 e pelo laudo de exame químico toxicológico realizado, fls. 100/102, prova técnica que atestou serem maconha, cocaína, crack e lança-perfume as substâncias apreendidas em poder do acusado. A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo. Na fase policial o réu confessou a prática delitiva e em juízo manteve a confissão. Alegou que estava com as drogas descritas na denúncia e ganharia R\$ 200,00 pelo "turno" no tráfico. Sua confissão foi corroborada diante dos relatos apresentados pelos policiais. Com efeito, disseram os agentes públicos que estavam em patrulhamento pela via e notaram que o réu, que estava sozinho, escondeu uma bolsa preta atrás de uma sucata de uma máquina de lavar. Estavam a pouca distância e puderam ver perfeitamente o que ele fazia. Quando ele notou a presença dos policiais, tentou fugir, mas foi abordado, até mesmo porque o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Na bolsa preta a qual ele escondera encontraram drogas diversas, maconha, crack e cocaína em quantidade considerável, além de lança perfume para comércio. O acusado admitiu que estava na prática do tráfico desde a noite anterior e que ganharia R\$ 200,00 pelo "turno" do serviço. Foi encontrada quantia em dinheiro na mesma bolsa. É diante do teor destes depoimentos que se autoriza a condenação do réu, já que absolutamente coerentes os relatos apresentados pelos policiais, os quais ainda vieram ratificados pelo teor da confissão e pela prova da apreensão do entorpecente e da própria bolsa onde guardados, conforme auto de fls. 09/10. Importa frisar que os depoimentos dos policiais não merecem reparos quando acompanhados de outros elementos de prova, quando prestados em uníssono, com coerência e plena segurança, sendo esta a hipótese dos autos. Este o entendimento dominante nos Tribunais, confira-se: "(...) Com relação à prova condenatória - depoimentos de policiais - sempre afirmo que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a juízo mentir, acusando uma pessoa inocente. Sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. (...)” (STJ HC 372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017). Ademais, é de ser salientado que os policiais sequer conheciam o réu, como afirmaram, e que, ainda que o réu tenha dito que os conhecesse, deu conta de que nada tem contra eles, que inclusive o aconselharam a mudar de vida. Desta forma, vejo que não há qualquer elemento que indique que teriam interesse em incriminar injustamente uma pessoa inocente. Noutro giro, na medida em que tinha o réu quantidade razoável de entorpecente em porções individuais e foi encontrado, em tais condições, em ponto indicado como de tráfico, é de ser condenado nos termos da imputação inicial, cabendo ressaltar que “para que

haja tráfico, não é mister seja o infrator

colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347). Procedente a demanda, passo à dosimetria da pena. O réu é primário e observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, não encontro circunstâncias que excedem o desvalor inerente ao tipo, com a ressalva de que a diversidade das drogas será considerada pelo juízo, mas na terceira fase, não podendo aqui ser tomada, pena de bis in idem. Fixo a pena-base, pois, no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase não há agravantes a computar e a atenuante da confissão não aproveita ao acusado, já que não teria o condão de trazer as penas para aquém dos mínimos, pelo que mantida a pena base aplicada. Na terceira fase, em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, reduzo as penas na metade, estabelecendo-as em definitivo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na ausência de causas de aumento da pena. Faço consignar que a existência da ação penal em curso mencionada pela Dra. Promotora de Justiça, em que condenado o réu pela prática de outra conduta anterior identificada como tráfico de entorpecentes, não pode ser considerada em prejuízo do réu, já que milita em seu favor o princípio do estado de inocência, sendo ele tido como primário aos olhos deste juízo até trânsito em julgado de outra decisão condenatória. Nesta medida, por não comprovado à saciedade que envolvido com a criminalidade quando dos fatos tratados nestes autos, deve ser aplicado in casu o preceito do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, quanto mais por não haver qualquer outro elemento nos autos que indique à conduta criminosa recorrente e não isolada. Faço ainda salientar que o E. Supremo Tribunal Federal, decidindo o tema 129 da Repercussão Geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Presidente), Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, firmando-se a tese de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como Maus Antecedentes para fins de dosimetria da pena, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.054 SANTA CATARINA RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO, julgado em 17.12.2014. Quanto ao regime de cumprimento da pena, vejo ser o réu primário, não podendo se considerar, na linha do que decidiu o mesmo E. Supremo Tribunal Federal tenha praticado crime hediondo. No contexto, favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo-lhe o regime aberto para desconto da pena. Deixo de substituir esta pena corporal por restritiva de direito em razão da insuficiência desta reprimenda no caso em apreço à finalidade ressocializadora que se pretende emprestar à reprimenda, a considerar que o crime em cuja prática se viu envolvido o imputado remete a inúmeras outras práticas delituosas e que redes criminosas se formam por sua conta (artigo 44, III, do Código Penal). As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal. Do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu RAFAEL HENRIQUE TOLEDO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto, e à pena pecuniária 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal. À vista do regime de cumprimento ora imposto para início do cumprimento da pena, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado. Transitada em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da reprimenda. Autorizo a destruição do entorpecente e da bolsa apreendidos e declaro o perdimento da quantia em favor do FUNAD, comunique-se. Isento o réu do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária, devendo ser observado o que

dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Pelo Ministério Público foi dito que interpunha recurso de apelação da decisão. Pela Defesa e pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer. Pela MM. Juíza foi dito: recebo o recurso interposto. Processe-se. Abra-se vista ao Ministério Público para apresentação das razões e, após, à Defensoria para contrarrazões. Oportunamente subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com as nossas homenagens. Cientes e intimados os presentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,_____, (MARCONDES) Assistente Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MMª. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita